

1500148-39.2021.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANILO BRAIT

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... E. TJ/SP já decidiu que: "Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

2ª Vara Criminal

Praça Maurício Martins Leite, nº 60 - Vila São Paulo - Araçatuba/SP - CEP 16015-925

1500148-39.2021.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500148-39.2021.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

ANDREI FERREIRA AGUERA

Réu Preso

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANILO BRAIT

Vistos.

ANDREI FERREIRA AGUERA, qualificado nos autos, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 porque, segundo consta na denúncia, no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 23h06min., na Avenida Ortêncio Giron, nº 453, Bairro Águas Claras, nesta cidade de Araçatuba-SP, o réu trazia consigo, sem autorização legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 283,73 gramas de Benzoilmetilecgonina (distribuídos em 946 pedras de "crack"), substância entorpecente vulgarmente conhecida por cocaína, capaz de causar dependências física e/ou psíquica.

O réu foi preso em flagrante em 22/01/2021 (fl. 05). Pela r. decisão de fls. 54/59, a prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva. Mandado de prisão cumprido em 22/01/2021 (fls. 73/74).

Devidamente notificado (fl. 132), o acusado apresentou defesa prévia às fls. 113/130. A denúncia foi recebida em 11 de março de 2021 (fls. 142/143). Pela r. decisão de fls. 178/179, foi determinada a instauração de incidente de dependência toxicológica do acusado, com apresentação de quesitos pelo juízo e as partes (fls. 182/184 e 188/189). O laudo pericial foi juntado às fls. 337/343. Durante a instrução processual foram ouvidas uma testemunha de acusação, uma testemunha em comum e uma testemunha de defesa, sendo, ao final, interrogado o réu (fls. 171/173 e 281/285).

Em alegações finais (fls. 347/352), o Ministério Público pugnou, em síntese, pela procedência da ação penal nos moldes da denúncia, uma vez que comprovadas a materialidade e autoria delituosa. Na dosimetria da pena, requereu o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, tendo em vista que o acusado está sendo processado pela prática de outro crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Em alegações finais (fls. 355/368), a Defesa pugnou, em síntese, pela absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, pela ausência de provas de que concorreu para a prática do crime ou por não existir provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta imputada na denúncia para a prática do delito previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no patamar mínimo legal, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, deferindo ao réu o direito de recorrer em liberdade. Por fim, pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É o relatório.

FUNDAMENTO.

O pedido inicial é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fl. 12/13), laudo de constatação prévia de substância entorpecente (fl. 32), laudo de exame químico-toxicológico definitivo de fls. 85/87, laudo pericial de fls. 90/92, relatório final (fls. 93/94), bem como pela prova oral colhida nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria também é certa.

A testemunha de acusação Josias Guerrero Junior, policial militar ouvido em juízo (fl. 173), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 06), disse que na data dos fatos estava em patrulhamento pelo bairro Águas Claras quando, ao passar pela Rua Ortêncio Giron, nº 453, avistaram um indivíduo na calçada conversando com outro rapaz, que estava do lado de dentro do portão da residência. O rapaz imediatamente correu para dentro do imóvel, momento que o depoente saiu em seu encalço. Relatou que, enquanto corria para o interior da casa, no corredor, o acusado arremessou um objeto para o telhado. Disse que conseguiu deter o réu nos fundos do imóvel, ao passo que os outros policiais detiveram o indivíduo que estava na calçada. Não encontrou nada de ilícito na posse do acusado, apenas a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). O acusado disse que não havia nada de errado em sua casa e apenas era usuário de drogas. No entanto, o indivíduo abordado do lado de fora da residência disse que estava ali para comprar drogas e, inclusive, já tinha comprado entorpecentes outras vezes no local. Afirmou que o indivíduo estava com R\$ 30,00 (trinta reais) no bolso e iria realizar a compra de 03 (três) pedras de "crack", mas não sabia o nome do acusado. Ao realizar a busca no imóvel, os policiais encontraram em cima do telhado um pote branco

contendo várias pedras de "crack". Disse que também encontraram, dentro de uma telha, uma quantidade maior de drogas, bem como uma balança de precisão. Assim que encontraram os entorpecentes, o acusado não falou mais nada. No interior da casa localizaram somente a quantia de R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais). Relatou que não conhecia nenhum dos indivíduos abordados. Disse que próximo ao local dos fatos há relatos sobre o tráfico de drogas, porém, naquela residência específica não tinha informações sobre o ilícito. Informou que na residência se encontravam mais duas pessoas, sendo a esposa do acusado e uma criança de colo. Não recorda o nome da esposa do réu. Reiterou que no bairro Águas Claras existem vários pontos de vendas de drogas e que os indivíduos abordados na rua sempre mencionam que compram os entorpecentes na região. No entanto, desconhecia o fato de a casa do acusado se tratar de ponto do tráfico de drogas, bem como os imóveis vizinhos. Relatou que a esposa do réu presenciou a abordagem policial. Afirmou que as drogas localizadas dentro do pote e da telha eram idênticas e possuíam, inclusive, a mesma embalagem.

A testemunha comum Maxwell Jonathan dos Santos, ouvido em juízo (fl. 282), em consonância com seu depoimento colhido na fase inquisitiva (fl. 07), disse que na data dos fatos tinha conversado com o acusado antes, para comprar a droga na residência do réu, sendo que ao chegar no local se deparou com a polícia. Enquanto alguns policiais entravam na casa para vistoriar o local, o depoente ficou em frente à residência, com outros policiais. Afirmou que era a segunda vez que o depoente realizava a compra de entorpecentes com o acusado. Disse que comprava do réu maconha e "crack". Não sabe dizer se o acusado vendia drogas há muito tempo, pois não mora no bairro. A primeira vez que comprou droga com o réu tinha sido recentemente. O depoente ficou sabendo que o acusado vendia drogas através de comentários de pessoas que adquiriram entorpecentes com ele. Disse que não chegou a comprar a droga. Relatou que já tinha sido atendido pelo acusado quando a polícia chegou ao local. Não sabe dizer a quantidade de droga que foi apreendida na ocasião. Relatou que os policiais não encontraram nada na posse do réu, apenas localizaram a droga dentro da residência. Reiterou que no momento das buscas no imóvel o depoente estava na calçada e não viu nada. Disse que apenas visualizou as drogas apreendidas na Delegacia. Acredita que os policiais só realizaram as buscas no interior do imóvel.

A testemunha de defesa Juliana Cristina Nogueira Alves, ouvida em juízo (fl. 283), disse que conhece o acusado, pois ele mora a três casas de distância da residência da depoente. Não sabe ao certo o número da casa, porém, disse que fica na Rua Ortêncio Giron. Não sabe dizer se o acusado é usuário ou vende drogas. Relatou que faz unha e cabelo com a esposa do acusado. Na data dos fatos, a depoente presenciou o ocorrido, pois estava sentada em frente à sua casa. Disse que a viatura do BAEP estava passando pelo local, momento que parou em frente à casa do acusado e imediatamente os policiais entraram no imóvel. Relatou entrou em sua casa e comentou o fato com seu marido. Disse que ficou olhando a ocorrência, assim como outros vizinhos. Afirmou que viu os policiais subirem no telhado da casa vizinha e da casa de baixo. O policial desceu do telhado da casa do vizinho com uma sacolinha. Os policiais ficaram no local por um tempo e depois conduziram o acusado para a Delegacia. Afirmou que o réu não foi abordado em frente à sua casa. Relatou que os policiais subiram em todos os telhados dos imóveis vizinhos. Afirmou que não viu ninguém em frente à casa do acusado. Disse que os fatos ocorreram durante a noite. Conseguiu visualizar os policiais saindo com uma sacolinha, pois na casa de baixo tem um poste com luz. Reiterou não saber se o acusado usa drogas e se faz uso de remédios controlados. Disse que, às vezes, frequenta a casa do réu, pois a esposa dele é manicure e cabeleireira. Informou que durante o ocorrido havia outras pessoas na rua que observaram os fatos. A depoente estava com seus filhos e seu marido, os quais também viram a ocorrência.

Em seu interrogatório em juízo (fl. 281), o réu Andrei Ferreira Aguera negou a prática do delito. Disse que na data dos fatos estava em sua casa com sua esposa e seus três filhos, quando uma motocicleta parou em frente à residência e buzinou.

Relatou que estava se alimentando e foi em direção à porta. Chegando na porta, ouviu um carro em alta velocidade, visualizando que se tratava de uma viatura policial, a qual abordou o rapaz da motocicleta. Afirmou que retornou à sua casa e disse para sua esposa que a polícia estava "enquadrando" um rapaz. Disse que o portão da residência abriu de uma vez e três policiais militares foram na sua direção, gritando "deita, deita, deita". Relatou que começou a passar mal, pois tem arritmia cardíaca, sendo que colocou a comida no chão e se deitou. Narrou que os policiais o seguraram pelo colarinho e o colocaram sentado no quintal de sua casa. Naquele momento, os policiais perguntavam "cadê a arma e as drogas?". Disse aos policiais que não tinha nada. Os policiais questionaram se o interrogando tinha alguma passagem criminal, sendo que respondeu sim e estava aguardando o julgamento. O policial afirmou que havia droga na residência e iria encontra-la, bem como prender sua esposa e levar seus filhos ao Conselho Tutelar. Afirmou que alguns policiais pegaram uma escada e subiram no telhado, enquanto outros policiais entraram na residência e reviravam as coisas. Os policiais desceram do telhado, colocaram a escada ao lado de sua casa e, após cerca de 15 (quinze) minutos, escutou um pulo. Disse que estava vendo a porta da sua casa, quando o policial retornou com uma sacola grande nas mãos e veio arrastando os móveis. O interrogando perguntou por qual motivo estava sendo preso e os policiais o mandaram calar a boca. Relatou que foi conduzido até a DIG e recebeu a informação que estava sendo preso por tráfico de drogas. Afirmou que não tinha nenhum dinheiro em sua posse, sendo que possuía apenas U\$ 2,00 (dois dólares), que seu pai tinha entregado e guardava de recordação. Não tinha ciência das drogas apreendidas. Afirmou que não sabe onde os entorpecentes foram encontrados, pois no momento das buscas o interrogando estava sentado com as mãos para trás e cabeça baixa. Visualizou apenas um dos policiais colocando a escada ao lado da sua casa e pulou para dentro de outra residência, sendo que escutou um barulho forte e avistou um policial nos fundos passando uma sacola grande para outro policial. Afirmou que era usuário de "crack", mas no momento dos fatos já tinha parado de usar. Relatou que foi condenado por tráfico de drogas, pois a polícia encontrou 10 (dez) pedras de "crack" em sua posse. No primeiro momento, disse que não conhecia a testemunha Maxwell, no entanto, posteriormente disse que lembra de tê-lo conhecido na 'biqueira'. Afirmou que não conversou com Maxwell na data dos fatos e o encontrou apenas na Delegacia. Na data dos fatos estava trabalhando como pintor e estava sem dinheiro, pois iria receber na sexta-feira ou na próxima segunda-feira. Questionado sobre o dinheiro apreendido pelos policiais, disse que em sua casa não havia nenhuma quantia.

Encerrada a instrução processual, restou demonstrado nos autos que os entorpecentes apreendidos pertenciam ao acusado e se destinavam à comercialização ilícita, diante do que foi declarado pelas testemunhas de acusação e comum em juízo, bem como pelas circunstâncias fáticas em que as drogas foram encontradas.

O policial militar Josias Guerrero Junior confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, afirmando em juízo que durante patrulhamento avistou o acusado no portão de sua residência conversando com a testemunha Maxwell, sendo que o réu, ao visualizar a viatura policial, correu para dentro do imóvel e dispensou um pote branco no telhado.

A testemunha relatou que o acusado tinha em sua posse a quantia de R\$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), sendo que em cima do telhado da residência foi localizado o pote branco contendo várias pedras de "crack". De acordo com o policial militar, dentro de uma telha havia grande quantidade de drogas, idênticas às encontradas no pote arremessado pelo réu, além de uma balança de precisão, totalizando 946 (novecentos e quarenta e seis) pedras de "crack". No interior da residência, também foi apreendida a quantia de R\$ 770,00 (setecentos e setenta reais).

O agente público afirmou, ainda, que a testemunha Maxwell, abordado do lado de fora

da residência, admitiu que estava no local para comprar 03 (três) pedras de "crack" com o acusado, pelo valor de R\$ 30,00 (trinta reais) que trazia consigo e, inclusive, já tinha comprado entorpecentes outras vezes naquele local.

Neste passo, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, visto que, constitucionalmente, são os policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestarem testemunho sob o compromisso da lei.

No mesmo sentido, se deu o depoimento em solo judicial da testemunha Maxwell Jonathan dos Santos, ao afirmar que o acusado vendia entorpecentes e foi até o local para adquirir drogas, sendo que ao ser atendido pelo réu, ambos foram abordados pelos policiais militares. Ainda de acordo com a testemunha, era a segunda vez que realizava a compra de entorpecentes com o acusado, sendo que a droga foi localizada pelos policiais no interior do imóvel do réu.

Não há motivos para desmerecer as palavras das testemunhas, uma vez que confirmadas pelo auto de exibição e apreensão de fls. 12/13, bem como pelos laudos periciais de fls. 32, 85/87 e 90/92.

Registre-se que os relatos prestados pelo policial militar e a testemunha comum são coincidentes entre si, estando em conformidade com os depoimentos colhidos na fase inquisitiva (fls. 06/07), o que lhes confere maior densidade probatória, não havendo nenhuma contradição relevante que se presta a abalar, minimamente, a credibilidade das testemunhas.

No caso vertente, nada há nos autos a sugerir que os policial militar e a testemunha teriam mentido em juízo e "forjado" o flagrante das drogas, balança de precisão e das quantias em dinheiro localizadas na posse do acusado e em sua residência para tentar prejudicá-lo. Também não há motivos para acreditar que os policiais não tenham visualizado o acusado conversando com a testemunha Maxwell defronte sua residência, momento que empreendeu fuga para o interior do imóvel e arremessou o pote contendo parte dos entorpecentes no telhado, com a única finalidade de incriminá-lo, como afirmou em seu interrogatório.

Como é cediço, o testemunho policial e de usuários da droga é de grande valia na prova do tráfico, não tendo sua credibilidade reduzida em razão de tais condições, salvo na presença de indícios concretos que possam desaboná-los, o que não se demonstrou, nem sequer por indícios, no curso do presente feito, tendo em vista que as testemunhas afirmaram em juízo que não conheciam o acusado.

Caracteriza-se, portanto, a prova produzida, como mais um elemento no conhecimento dos fatos pelo julgador, que deve apreciá-la em conjunto com as demais provas existentes nos autos.

Quanto ao acusado, não obstante tenha negado a propriedade dos entorpecentes e a prática do delito tanto na seara policial (fl. 08), quanto em juízo, observa-se que sua versão exculpatória restou isolada nos autos, sendo infirmada pelas testemunhas de acusação e comum ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Registre-se que a dinâmica dos fatos narrada pelo réu em solo judicial diverge em vários pontos daquela apresentada na seara policial, sobretudo quanto ao fato de o acusado conhecer a testemunha Maxwell e de que foi surpreendido pelos policiais no momento que atendia Maxwell no portão da sua residência, tendo afirmado também na fase inquisitiva que correu para o interior do imóvel ao visualizar a chegada dos agentes públicos no local, exatamente como relatado em juízo pelas testemunhas Josias e Maxwell.

Com efeito, ao alterar a dinâmica dos fatos em solo judicial – afirmando que estava no interior da residência com sua família, momento que os policiais invadiram o imóvel, ordenaram que o réu se deitasse no chão e perguntaram onde estavam as armas e as drogas, sendo que os agentes públicos foram até o imóvel vizinho e retornaram com uma sacola nas mãos, negando a existência dos entorpecentes e apetrechos na sua residência – tenho que sua narrativa é inverossímil e não merece credibilidade.

Embora a testemunha de defesa Juliana Cristina Nogueira Alves, vizinha do acusado, tenha afirmado em juízo que não havia ninguém na frente da residência do réu – uma vez que a testemunha teria presenciado a chegada dos policiais militares no local, os quais ingressaram imediatamente no imóvel do acusado e depois subiram nos telhados das casas vizinhas, ocasião em que um dos policiais desceu com uma sacola nas mãos – verifica-se que sua narrativa também foi infirmada pelas demais testemunhas ouvidas nos autos, os quais foram unânimes ao relatarem que o acusado estava atendendo Maxwell defronte sua residência, momento em que foram surpreendidos pelos policiais militares que passavam pelo local.

De mais a mais, ressalta-se que a testemunha Maxwell foi contundente ao afirmar que o acusado estava vendendo entorpecentes em sua residência. Portanto, tenho que as provas colhidas nos autos permitem concluir, sem sombra de dúvidas, que os entorpecentes pertenciam ao acusado.

O modo como as drogas estavam acondicionadas e a quantidade apreendida configuram também que se destinavam ao tráfico. Isto porque, foram apreendidos 946 (novecentos e quarenta e seis) porções de substância petrificada amarela, acondicionadas em trouxinhas de plástico azul, perfazendo o total de 283,73 gramas da substância entorpecente Benzoilmetilcgonina, popularmente conhecida como cocaína, na forma de "crack" (fls. 32 e 85/87).

Registre-se que no mesmo contexto fático – dentro da telha da residência do réu, onde estava parte dos entorpecentes – foi apreendida uma balança de precisão contendo resquícios da droga (conforme laudo pericial de fls. 90/92), tratando-se de instrumento comumente utilizado por traficantes para fracionar e pesar a droga.

De igual modo, também foram apreendidas as quantias de R\$ 1.120,00 (um mil, cento e vinte reais) e US\$ 2,00 (dois dólares) em espécie – conforme fls. 12/13 e 84 –, não tendo o acusado comprovado a origem lícita do dinheiro, o que corrobora com a versão das testemunhas de acusação e comum de que estava traficando drogas na residência, uma vez que é comum que os traficantes carreguem consigo os valores em notas diversificadas, oriundos das vendas que realizam, demonstrando a relação do numerário com o comércio nefasto da droga.

Cabe ponderar que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes é de natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga sendo, portanto, desnecessário que o agente seja flagrado em atos de mercancia ou na posse de apetrechos comumente utilizados para a prática do delito, conforme sustentado pela defesa.

A propósito, sobre o tema o E. TJ/SP já decidiu que: “Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio artigo 37 da Lei Antitóxicos dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente.” (RT 584/347. Nesse mesmo sentido: RT 714/357, RJTJSP63/316, 70/371 e 97/512).

De mais a mais, ainda que se admitisse que o réu também fosse usuário da droga –

conforme alegado pela defesa -, tal fato, por si só, não exclui a prática do crime, provado no caso vertente, uma vez que é muito comum que alguns usuários revendam o entorpecente para sustentar o próprio vício, circunstância que não afasta a tipicidade e responsabilidade penal, razão pela qual também não comporta acolhimento o pedido defensivo de desclassificação da conduta imputada ao réu.

Por fim, não há que se falar em absolvição do acusado com base em seu histórico de dependência química, em razão do vício em drogas ao longo dos anos e ao agravamento de sua patologia, conforme sustenta a defesa em alegações finais.

Isto porque, o exame pericial de insanidade mental / dependência toxicológica realizado no réu e acostado às fls. 337/343, concluiu que o acusado era, ao tempo da ação, "plenamente capaz de entender e de se determinar" (fl. 340), não havendo se cogitar eventual inimputabilidade.

Nesse sentido, não se encontra presente a excludente de culpabilidade prevista no artigo 26, do Código Penal, diante da comprovada voluntariedade no consumo de entorpecentes e o dolo consciente na prática do delito ora imputado. Com efeito, não se comprovou nos autos que o réu era dependente químico ao tempo da ação, tornando-o doente mental, o que afastaria sua culpabilidade.

Portanto, as provas são robustas a sustentarem um decreto condenatório, não merecendo acolhimento a tese defensiva de absolvição por ausência de provas de que o acusado concorreu para a prática do crime ou por não existir provas suficientes para a condenação, uma vez que ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 386 do Código de Processo Penal.

Com efeito, as condutas do réu, consistentes nas ações de "trazer consigo" e "ter em depósito" os entorpecentes, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, encontram-se inseridas no rol descrito no "caput" do artigo 33, da Lei nº 11.343/06.

Analisando os autos, é incabível a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, em favor do acusado.

Conforme já assentou o C. Superior Tribunal de Justiça, a inserção no ordenamento jurídico da causa de diminuição de pena (tráfico privilegiado) teve por escopo diferenciar aquele agente que não é dedicado à prática de ilícitos penais, daquele que efetivamente se dedica ao tráfico de entorpecentes com maior potencialidade lesiva à sociedade, sendo que a aplicação da benesse não pode ocorrer de forma desmedida, mas somente em casos singulares, quando o agente preenche cumulativamente todos os requisitos, os quais merecem interpretação restritiva, de modo a prestigiar quem efetivamente mereça redução de pena (REsp nº 1.380.741/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/4/2016, DJe 25/4/2016).

Nesse sentido, entendo que o benefício não foi pensado para situações como a retratada nos autos, em que o acusado já foi processado e condenado definitivamente pela prática do tráfico ilícito de entorpecentes em data anterior - processo nº 1500339-21.2020.8.26.0603 -, conforme pesquisa realizada no Portal E-SAJ nesta ocasião e confirmada pela certidão de objeto e pé de fls. 375/377.

Sendo assim, diante da condenação penal, bem como as demais circunstâncias do delito e elementos de prova existentes nos autos, restou demonstrado que o réu não se trata de traficante eventual, mas sim, de que se dedica habitualmente às atividades ilícitas, bem como ostenta maus antecedentes por crime da mesma natureza, o que justifica o afastamento do redutor previsto no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, sendo também incabível na hipótese dos autos a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena. A lei é taxativa quanto aos pressupostos para a concessão das benesses, sendo tal rol cumulativo e, dentre

eles, exige-se a primariedade e os bons antecedentes.

Em razão de todo o acima exposto, restou demonstrada e caracterizada a conduta do réu pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Passo à fixação da pena.

No tocante às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes por conta da condenação criminal definitiva nos autos do processo nº 1500339-21.2020.8.26.0603 - trânsito em julgado em 07/07/2022, conforme pesquisa no Portal E-SAJ que foi confirmada pela certidão de fls. 375/376, ainda que tenha se dado posteriormente ao presente ilícito penal, nos termos da iterativa jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.711.015/RJ - QUINTA TURMA; AgRg no AREsp nº 1.073.422/DF - SEXTA TURMA). Diante disso, fixo a pena-base acima do patamar mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixada no patamar mínimo de 1/30 do salário mínimo, uma vez que ausentes nos autos elementos que permitam aferir a capacidade financeira do acusado.

Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição de pena a serem aplicadas. Inviável, no caso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, como delineado na fundamentação supra, razão pela qual torno definitiva a pena acima estabelecida.

Tratando-se de crime equiparado a hediondo (art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90), excepcionalmente, considerando no presente caso as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e o artigo 59 do Código Penal, os maus antecedentes e o montante da pena imposta, tenho que o réu deverá iniciar o cumprimento de sua pena no regime semiaberto.

Também em razão dos maus antecedentes e do montante da pena imposta, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena (sursis), por conta de estarem ausentes os requisitos previstos no artigo 44, incisos I e III, e artigo 77, "caput", inciso II, ambos do Código Penal, bem como por não se considerar aptas para retribuição e prevenção da pena as mencionadas substituição e fixação de regime prisional menos gravoso no presente caso, além de causar verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Araçatuba-SP.

DECIDO.

Ante o acima exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público para CONDENAR o réu ANDREI FERREIRA AGUERA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa no valor de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, com regime semiaberto para o início do cumprimento.

INDEFIRO ao réu o direito de recorrer em liberdade pelos mesmos fundamentos explicitados para a decretação e manutenção de sua prisão preventiva, somados à gravidade do crime imputado, bem como para assegurar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal, sobretudo agora diante da condenação, em razão do montante e regime de pena impostos.

Recomende-se o réu ao estabelecimento prisional onde se encontra. Após, com a intimação das partes acerca da presente sentença, expeça-se, com urgência, guia de recolhimento provisória/definitiva.



DECLARO o perdimento das quantias apreendidas nos autos (R\$ 1.120,00 e U\$ 2,00 - fls. 12 e 84) em favor da União, nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, uma vez que são produtos do crime praticado pelo sentenciado, expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Por fim, DETERMINO a destruição da balança digital também apreendida nos autos (fl. 12), por estar relacionada com a prática do crime em questão (cf. laudo pericial de fls. 90/92), expedindo-se o necessário após o trânsito em julgado.

Custas conforme a lei (artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003), observando-se os benefícios da assistência judiciária gratuita que defiro ao sentenciado nesta ocasião. Anote-se.

P. R. e I.

Araçatuba, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA